

1500576-91.2022.8.26.0439

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Correa Ortega

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2188680/2022 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 26091844 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2188680 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2188680/2022 - DEL.POL.PEREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

2ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500576-91.2022.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500576-91.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2188680/2022 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 26091844 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2188680 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2188680/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ALVES DA SILVA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo TIAGO ALVES DA SILVA DOS SANTOS e CLEIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, todos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia: a) no dia 12 de julho de 2022, aproximadamente às 16h, na residência localizada na Rua Coronel Basileu Estrela nº 3312, bairro Vila Nova, Pereira Barreto, os réus, com dados de qualificação às fls 85/86, tinham em depósito para posterior entrega a consumo de terceiros 222 gramas da substância "cannabis sativa L", popularmente conhecida como maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls 27, fotos de fls 28, auto de constatação provisório de fls 29/30 e exame químico-toxicológico; b) nas

mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, os denunciados se associaram para fim de praticar o crime de tráfico de drogas [fls 129/131]. De início, o denunciado Tiago foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva [fls 01 e 49/57].

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Cleia Alves da Silva dos Santos [fls 85/91].

Defesa prévia por parte do investigado Tiago apresentada extemporaneamente, antes mesmo da denúncia [fls 73/76], tendo sido impetrado, ademais, habeas corpus preventivo em favor da paciente Cleia [fls 95/111].

Na denúncia, o Ministério Público solicitou diligências, manifestando-se por aguardar o resultado destas para se manifestar sobre a prisão [fls 124/128].

Por decisão de fls 132/135, o pedido de busca e apreensão pleiteado pelo Ministério Público, em relação ao celular da denunciada Cleia foi deferido, assim como foi deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos.

A liminar requerida em habeas corpus foi indeferida [fls 164/165], prestando este magistrado as informações solicitadas [fls 176/177].

Requeriu o Ministério Público fossem oficiadas as instituições financeiras onde os denunciados possuem contas, com solicitação de informações sobre as movimentações financeiras dos últimos quatro meses [fls 195].

O pedido foi deferido, decretando-se a quebra do sigilo bancário [fls 196/198].

Em busca e apreensão, foi apreendido um aparelho telefônico celular e um bloco de anotações [fls 221/222].

Laudos periciais juntados às fls 227/233, 235/237 e 238/239.

A liminar pleiteada perante o Superior Tribunal de Justiça também foi indeferida [fls 284/287], prestando este magistrado as informações solicitadas [fls 288/289].

A denúncia foi aditada [fls 322/325].

Esclareceu a autoridade policial o quanto solicitado por este magistrado [fls 356/357 e 372].

A denúncia foi recebida, determinando-se a retificação das informações prestadas em habeas corpus [fls 374/379 e 410/412].

Regularmente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação [fls 397/403].

Manifestou-se o Ministério Público [fls 407/409].

O a denúncia e seu aditamento foram recebidos [fls 410/412].

Ofícios bancários colacionados aos autos [fls 415/468].

Foi concedida liminar em Habeas Corpus pelo C. STJ [fls 491/499]. Alvará de soltura expedido [fls 503/504].

Laudos juntados [fls 513/515 e 516/522].

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

As partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais. O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, condenando-se o acusado Tiago, apenas, no que tange ao tráfico de entorpecentes, absolvendo-o do delito previsto no artigo 35, da Lei Antidrogas, absolvendo-se a acusada de ambos os delitos. A defesa dos acusados pleiteou a absolvição [fls 553/566 e 567/582].

É o relatório.

Fundamento.

É fato que à acusação cabe a prova do que alega. Mas isto não afasta o dever de a defesa constituir elementos robustos que contrariem de modo razoável e plausível tudo o que o Ministério Público trouxe, em termos documentais, e o que foi produzido em desfavor, em termos testemunhais. Há um sensível matiz do qual não se pode afastar: É ônus da defesa provar o que alega, pois *allegare sine probare et non allegare* paria sunt alegar e não provar é o mesmo que não alegar (Nicola Framarino dei Malatesta. A Lógica das Provas em Matéria Criminal, São Paulo: Saraiva, 1960, p. 179). Com todo o vigor tem cabida, como referido, o brocardo *allegare sine probare et non allegare* paria sunt (alegar e não provar é o mesmo que não alegar). Nesse sentido leciona também HÉLIO TORNAGHI: "O sentido do artigo 156 (do CPP) deve ser esse: ressalvadas as presunções, que invertem o ônus da prova, as alegações relativas ao fato constitutivo da pretensão punitiva têm de ser provadas

pelo acusador e as referentes a fatos impeditivos ou extintivos deve ser provados pelo réu" (HÉLIO TORNAGHI. Instituições de Processo Penal, Forense, Rio, 1959, IV/232).

Pois bem. Exige-se para a condenação a certeza além da dúvida razoável. De forma diametralmente oposta, referida premissa não tem como consequência a necessidade de exaurimento de todas as teses apresentadas pelas partes, tanto para a absolvição quanto para a condenação. Resta suficiente que o magistrado proceda à análise dos fatos e provas expostas, esposando os pontos suficientes para fundamentar sua decisão. Eventual error in iudicando imputado ao órgão ministerial e à Defesa a necessidade de observância à dialeticidade para eventualmente, em sede recursal, afastar os fundamentos apresentados pelo órgão judicante em confronto com elementos permissivos dos autos, em busca da substituição da decisão por outra exarada pela I. Corte Recursal. Segue, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 22, CAPUT, DA LEI N. 7.492/86. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 625.263. DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES ALEGADAS PELA DEFESA. DEVIDA APRECIÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É da competência do Supremo Tribunal Federal a determinação de sobrestar na origem as ações penais cujas matérias foram reconhecidas como de repercussão geral. Precedente. 2. "Apesar de o artigo 5º da Lei 9.296/1996 prever o prazo máximo de 15 (quinze) dias para a interceptação telefônica, renovável por mais 15 (quinze), não há qualquer restrição ao número de prorrogações possíveis exigindo-se apenas que haja decisão fundamentando a dilatação do período" (HC 359.809/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017). 3. "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1611030/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) negrita-se.

Já, em relação ao disposto no inciso IX, da CR/1988, pacífico que a exposição limitada e suficiente para a conclusão não viola a Constituição da República, sendo desnecessárias decisões analíticas, desde que suficientemente fundamentada para a solução da lide. É o sentir da Corte Suprema: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Para Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) negrita-se. É como sempre disse, com maestria, em casos inúmeros, o Desembargador ilustre Souza Nery:

"Ao contrário do entendimento esposado pela douta e combativa defensoria, a condenação encontra suficiente lastro na evidência dos autos. Tenha-se, desde o início, em mente ser inaceitável exigir, para a prolação do édito condenatório, grau absoluto de certeza, condição incompatível com as limitações inerentes à natureza humana. O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida

significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo". Suficiente a embasar condenação penal é a evidência que, afastada a dúvida razoável, conduza à formulação de juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão, tal como ocorre nos presentes autos.(TACrimSP, apelações nºs. 1.233.007, 1.230.305, 1.229.065, 1.228.613, 1.226.185, 1.224.885, 1.223.501, 1.223.053, 1.222.347, 1.221.075, 1.220.813, 1.220.809, 1.219.127, 1.218.503, 1.217.039, 1.216.017, 1.215.709, 1.215.205, 1.215.151, C.7ª Câmara, TACrim, entre diversos outros).

Além do mais, ainda que seja ônus da acusação comprovar os fatos, os réus, ao apresentarem determinada tese defensiva, avocam para si o ônus de provar os atos e fatos argumentativos contrários.

Neste sentido: "PROVA. defesa fundamentada em fato singular. ônus da prova. Cabe ao acusado que fundamenta defesa em fato singular e contrário ao que normalmente ocorre em circunstâncias semelhantes, o ônus da prova do argumento." (JUTACRIM 54/243, Rel. VALENTIM SILVA). Preleciona Júlio Fabbrini Mirabete: "... ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes" (Código de Processo Penal Interpretado.11ª ed. São Paulo: Atlas. p. 474/475)

O pedido condenatório é improcedente.

Nada obstante o auto de prisão em flagrante [fls. 01]; boletim de ocorrência [fls 23/25]; auto de exibição e apreensão [fls. 27]; autos de constatação preliminar de substância entorpecente [fls. 29/30]; fotografias de fls 28; transcrições de fls 31/32 e laudos periciais de fls 227/233 e 235/237, ao cabo da instrução, não se verificou o cenário inicialmente descrito pela investigação.

Luís Fernando Baroni disse que é policial civil e que havia, na data dos fatos, dirigiu-se até a residência dos acusados para cumprir um mandado de busca. O imóvel era todo fechado e com câmeras, e o acusado Tiago foi encontrado num bar e conduzido até o local. Tiago chamou, mas demorou bastante tempo para que a acusada abrisse o portão. A testemunha afirmou que, no local, foram apreendidos uma porção de maconha, que foi entregue pela acusada Cleia, e um aparelho celular, após perícia no aparelho celular, foram encontrados indícios de que os acusados praticavam traficância de entorpecentes, a testemunha afirmou que, nas casas vizinhas, não havia utilização de câmeras de monitoramento, afirmou que não se recorda de outras denúncias contra os acusados.

Henrique Bevilacqua Torres relatou que é policial civil e que, na data dos fatos, cumpriu um mandado de busca no local dos fatos. A testemunha afirmou que a casa era toda trancada, com câmeras de segurança, e foi requisitado a um agente policial de outra unidade para ajudar na abordagem. O agente tocou a campainha, mas não foi atendido. O réu Tiago foi encontrado num bar e conduzido até o endereço, foi dada ordem para que Tiago abrisse o portão. A acusada demorou bastante tempo até que Cleia permitisse a entrada dos policiais. Na residência, foram apreendida uma porção de maconha e um aparelho celular, não foram encontrados apetrechos típicos de traficância, como balança de precisão, a testemunha afirmou que desconhece outras denúncias anteriores contra os acusados.

Edilson Fernando Belo afirmou que o acusado Tiago é carpinteiro e já prestou serviços para a testemunha, afirmou ainda que conhece outras pessoas que já contrataram o acusado e que o acusado presta bons serviços.

Fernanda de Oliveira afirmou que é contratante da acusada Cleia, a acusada presta serviço de faxina na residência da testemunha. A testemunha afirmou que a acusada é uma boa funcionária, não há nada que a desabone, afirmou que Cleia recebe 100 reais quando realiza faxina uma vez na semana, ou 150 reais, quando realiza a faxina duas vezes na semana, a testemunha afirmou que as vezes paga a acusada por PIX. O acusado TIAGO ALVES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que é carpinteiro e vive desta profissão. Disse que é casado com a acusada Cleia, e nega que tenha traficado, mas

afirma que é usuário de maconha. O acusado afirmou que Tutti é uma cliente que compra salgados da acusada Cleia. Afirmou que as conversas encontradas em seu aparelho celular referem-se à negociação de venda de salgadinhos produzidos por Cleia. Afirmou que os clientes citados nas conversas são tanto clientes dos serviços de carpintaria quanto clientes que compram salgadinhos ou contratam o serviço de faxina de Cleia. Afirmou que as conversas com Neto vizinho referem-se à venda de salgadinhos. O acusado afirmou que possui cinco cachorros em sua residência e que um dos motivos para ter instalado câmeras da residência é monitorar se alguém faria algo contra seus animais, afirmou que ficou preso preventivamente e durante este período perdeu alguns serviços de carpintaria e teve prejuízo financeiro neste período.

A acusada CLEIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS afirmou que é esposa do acusado Tiago, e disse que é faxineira e vende salgadinhos, afirmou que as imagens das câmeras de monitoramento de sua residência não estão mais disponíveis porque o sistema de gravação sobrepõe as gravações, afirmou que a conta no banco Santander é de sua titularidade, mas é utilizada tanto por ela quanto pelo acusado Tiago, afirmou que Tutti é uma de suas clientes que compra salgadinhos. Afirmou que Tutti e Luana são clientes frequentes e compram fiado. O preço para quem compra fiado é o mesmo cobrado de quem compra à vista. Afirmou que a movimentação da conta bancária referem-se tanto aos pagamentos dos seus clientes quanto dos clientes do acusado Tiago. A acusada afirmou que possui cinco cães em sua residência e que as câmeras foram instaladas em sua residência para monitorar os cães, afirmou que o DVR que guarda as gravações das câmeras ficou à disposição das autoridades policiais, mas em nenhum momento o DVR foi requisitado, contratou inicialmente o advogado Dr. Kelvin Kalil por indicação de um vizinho, afirmou que que houve um erro no registro da quantidade de entorpecentes apreendidos na data dos fatos.

Em que pese cuidar-se de casa extremamente monitorada, o que dá azo a uma verificação minudente de todo aquele que ali comparece, possibilitando, ainda, a destruição de possíveis provas que pudessem ali existir, fato é que, em concreto, a droga localizada efetivamente é compatível com uso de entorpecentes, mormente porque encontrado, na localidade, dichavador e papel de sede, insumos comumente utilizados por usuários de maconha.

Assim, nada obstante a existência de denúncias pretéritas, a meu sentir, a prova não é suficiente para um decreto condenatório.

Havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do in dubio pro reo.

“É preciso distinguir bem a probabilidade da certeza. Dá-se probabilidade quando a razão, apoiando-se em graves motivos, considera um fato verdadeiro, sem que, entretanto, os motivos sérios em contrário estejam completamente aniquilados. Resulta ela de que as provas, que deveriam por si mesmas estabelecer a verdade, se não apresentam na espécie com todas condições requeridas, ou que, em face dos motivos que fornece, outros se erguem em sentido inverso e também muito fundados, ou, enfim, de que a convicção repousa apenas sobre dados, que, apesar de sua reunião, não são ainda bastante poderosos para gerar a certeza. Em todos esses casos a probabilidade não pode servir de base para condenação, pois que há sempre ensejo para a dúvida, e a consciência só ficaria satisfeita quando desaparecesse a possibilidade do contrário” (TRATADO DA PROVA EM MATÉRIA CRIMINAL, p.60, C.J.A. MITTERMAIER, Ed. Bookseller, 3ed.)

Reitere-se: nesta abordagem, a quantidade apreendida, no contexto, permite margem para subsunção ao porte de entorpecentes para consumo próprio.

Como apontou o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus nº 144.716 SP, com grifos nossos: para efeito de mero registro, que a legislação portuguesa, em tema de drogas e substâncias afins, adotou, a partir da edição da Lei nº 30, de 29 de novembro de 2000, medidas despenalizadoras, instituindo, em determinados casos, tratamento médico-ambulatorial ou simples pagamento de multa, além de somente incriminar a conduta configuradora do delito de tráfico de entorpecentes quando o agente Possuir substâncias ilícitas cujo total supere “a quantidade necessária para consumo médio individual durante o período de 10 dias” (Lei nº 30/2000, art. 2º, item n. 2). É importante acentuar, em face do

que prescreve referido preceito normativo, que o Poder Judiciário português definiu, para efeito da regra em questão, que a quantidade para consumo médio individual para um período de dez dias equivale a 2 gramas (se se tratar de cocaína) ou a 25 gramas (se se cuidar de maconha). Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa – apoiando-se na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e da Saúde (que define os limites máximos “para cada dose média individual diária” referente a plantas, substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) –, tem entendido, em diversos julgados, que “os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g” (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLIVEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha (“cannabis sativa L.”), esse limite é de 2,5g. No processo criminal vigora o princípio, segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser coerente, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e da autoria.

Cabe lembrar, ainda, a lição de MALATESTA, segundo qual “o direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo; por isso, absolvendo um caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado e não oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranqüilidade social, mais do que a teria abalado o crime particular que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítimas de um erro judiciário. Lançai na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela mesma tranqüilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será a defensora do direito, e sim a força imane que pode, por sua vez, esmagar o direito indêbil” (in “Lógica das Provas”, Ed. Saraiva, págs. 14/15).

Não há certeza. Faz-se de rigor a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória para ABSOLVER TIAGO ALVES DA SILVA DOS SANTOS e CLEIA ALVES DA SILVA DOS SANTOS, qualificados, da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Faculto recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Pereira Barreto, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA